

1509989-82.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509989-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509989-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ADRIANO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 04h20, durante o repouso noturno, na Rua José Martí, nº 70, Jardim Colina, nesta cidade e comarca da Capital/SP, tentou subtrair, para si, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, fios de energia do interior da residência da vítima, o Delegado de Polícia Mauricio Correali, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 69/70).

A denúncia foi recebida (fls. 111/113), o réu foi citado e notificado (fls. 138/139) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 143).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 148).

Em 29 de junho de 2022, realizada a audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 148/151), foram ouvidas a vítima e a testemunha comum e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 148/150).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, em que pese a confissão do acusado, o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, pugnou pelo(a) i) fixação das bases nos mínimos legais; ii) afastamento da qualificadora do rompimento de

obstáculo; iii) reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação integral com eventual agravante da reincidência; iv) afastamento da causa de aumento do repouso noturno; v) aplicação do redutor pela tentativa em sua fração máxima; vi) fixação do regime inicial "diverso do fechado"; vii) detração penal; e viii) concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 150/151).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo(a)s Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04), Termos de Declarações (fl. 05), Termo de Interrogatório (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14), Fotografia da Alicate Apreendida (fl. 15), Relatório Final (fls. 29/31) e Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 132/137).

A autoria do crime ficou demonstrada pela sobretudo pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

A vítima Maurício Correia narrou que, no dia da ocorrência, por volta das 04h15, acordou após ouvir intenso barulho de movimentações entre o telhado e a laje de sua residência. Passou a escutar e verificou que estava sem energia na casa e parecia que havia fiação sendo puxada e removida - "e isso durante vários minutos". Acionou a Polícia Militar e a CEPOL, ante a certeza de que havia alguém em sua casa. O acusado entrou no imóvel "subindo por uma mureta lateral direita da casa". Não sabe como o réu acessou a parte do telhado. No telhado, havia telhas removidas e "a escuridão dentro do telhado". Depois de alguns instantes, as equipes policiais localizaram o furtador escondido. O acusado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial. Elucidou que parte da fiação já havia sido removida, "e, no jardim da garagem, havia um saco de lixo" onde os fios subtraídos provavelmente seriam acondicionados. Reconheceu o réu em juízo, "sem sombra de dúvidas". Suportou prejuízo de aproximadamente R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão do reparo da parte elétrica da residência, além de cerca de R\$ 700,00 (setecentos reais) do conserto do telhado, oriundo do "rompimento do obstáculo, de ripa quebrada etc". Acredita que a altura aproximada de seu telhado é de 2,10 m (dois metros e dez centímetros). Repisou que "teve que praticamente reinstalar a fiação de toda a casa, com uma equipe de eletricitas".

A testemunha João Luiz Gonçalves Freire, policial civil, contou que, no dia dos fatos, estava de plantão com sua equipe e, por volta das 04h, receberam chamado via CEPOL dando conta da existência de indivíduos no interior da residência do delegado Maurício. O ofendido recepcionou-os na entrada da residência e explicou que tinha percebido barulhos dentro da casa; ingressaram no imóvel e começaram a vasculhá-lo; não encontraram nada e resolveram subir no telhado. Notou que havia uma telha "meio que descoberta", entrou "pra dentro do forro" e encontrou o furtador - "ele estava abaixado, escondido". Recordou-se que "do lado" do acusado havia um alicate, e a fiação estava cortada - "lá em cima tinha muita fiação [...], tinha bastante fio". O réu disse que estava praticando o furto para sustentar o vício em drogas.

Reconheceu-o em juízo.

Em solo policial, o réu assumiu a prática delitiva (fl. 06).

Em juízo, ADRIANO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA confessou o cometimento do crime patrimonial - "foi exatamente isso que aconteceu mesmo". Não sabia de quem era a residência. Ansiava furtar os fios elétricos da moradia para "trocar em droga"; viu "uns matos" na frente da casa e ficou com a impressão de que não havia ninguém no local. Subiu ao telhado - "eu peguei e subi". Tinha acabado de sair do sistema carcerário. Assentou que poderia ter morrido, tendo em vista a profissão do ofendido. Necessita de ajuda para superar a dependência química.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

A confissão do réu, ao contrário do alegado pela combativa defesa técnica, veio devidamente corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha comum, colhidas sob o crivo do contraditório.

É de asseverar, ainda, que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada

significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Ainda, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha mantiveram os aspectos nucleares de forma congruente e concatenada quanto às narrativas apresentadas em solo policial (fls. 03 e 05). Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

As qualificadoras descritas na denúncia também vieram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, notadamente pelo laudo do local dos fatos de fls. 132/137.

O teor do exame e as fotografias são contundentes em apontar a escalada do muro e do telhado, bem como o rompimento de obstáculo pela retirada das telhas que guarneciam o teto do imóvel e pelo corte da tubulação elétrica para subtração dos cabos de cobre.

Nesse passo, não vinga o pedido de afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, tal como pretendido pela defesa técnica. Certamente o acusado não intencionava furtar o material envoltório dos fios, mas tão somente os componentes contidos em seu interior – fios de cobre.

Vale dizer, ADRIANO não atuou "contra a própria coisa", mas sim a fim de subtrair os elementos contidos no interior dos equipamentos, valendo-se, para tanto, do rompimento de obstáculo mediante o emprego de uma alicate (fl. 15).

De mais a mais, o acusado também rompeu as barreiras de proteção do telhado da casa ao retirar as telhas para furtar os fios elétricos no interior do imóvel.

Verifica-se também que o furto se deu durante o período noturno, fato este que foi devidamente descrito na denúncia.

Não há falar em afastamento do repouso noturno apenas em razão da posição topográfica do § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Neste ponto, compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há decisões baseadas na mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

Tal entendimento começou, então, a mudar, notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado-privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina, então, começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar, nestes casos, que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena.

Outras considerações, para não aplicar o aumento do § 1.º às formas qualificadas (§ 4.º ou § 5.º), constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena. Nesse sentido:

"Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)" (STJ – REsp 940.245-RS, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, 13.12.2007, v.u.); HC 10.240-RS, 6.ª T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ 14.02.2000, p. 79.

Em seu voto no HC 306.450/SP, a ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou: Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2.º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1.º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4.º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1.º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico.

Por outro lado, registra-se que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma desta Corte segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento, quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425/RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2.º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera tal ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º).

E, assim sendo, tendo em vista que o furto em tela é qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, não há qualquer óbice para aplicação da causa de aumento de pena (art. 155, § 1º, do Código Penal), devendo, portanto, ser mantida.

Cumprе destacar julgado que fixa justamente essa orientação ao enfrentar hipótese análoga:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. BEM AVALIADO EM R\$ 300,00. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA PENA-BASE. SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno – em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração –, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus [...] 5. Ordem denegada" (Processo HC 424098/SC – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

No mesmo sentido e, corroborando o entendimento ora esposado, o Supremo Tribunal Federal no HC 130952/MG, assim já se pronunciou:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C O ART. 14, II). CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º) NAS FORMAS QUALIFICADAS DO CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, § 4º). ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE CONTRADIÇÃO LÓGICA QUE POSSA OBSTAR A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DOS DOIS INSTITUTOS QUANDO PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO FÁTICA. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não a submeter às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) –, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada". (STF – HC 130952/MG, Relator

Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 13/12/2016 - Info 851).

No mais, tendo o acusado sido surpreendido enquanto retirava os fios de cobre sem que se afigurasse a inversão da posse da res furtiva, permanece bem delineada a tentativa de subtração.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas.

O réu possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, é solteiro e não tem filhos. Estudou até a 8ª Série; interrompeu os estudos porque foi preso já na juventude. Tem a vida marcada pela dependência química, sobretudo crack; consumiu-o pela primeira vez aos 14 (quatorze) anos de idade. Quando saiu da penitenciária, após ser condenado, voltou a consumir entorpecentes. Mora com sua madrastra, a qual considera "uma mãe", no "CDHU". Trabalha como pintor. Não há pessoa que dependa economicamente de seus rendimentos. Foi processado anteriormente; foi preso "umas cinco vezes"; quando era "mais novo", cometia crimes patrimoniais - "era assalto, mas nada de arma de fogo". Depois, começou a "furtar". Morou na rua de "85 a 86", "ia pra FEBEM e voltava"; morou na rua até os 16 (dezesseis) anos.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ - HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Ainda, anoto que o réu ostenta Maus Antecedentes pela prática de crimes patrimoniais (0015677-03.2012.8.26.0050 - furto qualificado tentado; 0044817-24.2008.8.26.0050 - furto qualificado tentado; e 0059617-81.2013.8.26.0050 - roubo impróprio - fls. 32/36 e 71/87).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/5 (um quinto), perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de ADRIANO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência específica do acusado pela prática de crimes patrimoniais (0052863-21.2016.8.26.0050 - roubo e desacato; e 1526559-17.2020.8.26.0228 - furto qualificado tentado - fls. 32/36 e 71/87). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência de ADRIANO, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: "Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]" (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021).

Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa, considerando a prática do delito durante o repouso do noturno, por força de previsão legal a pena deve ser aumentada no coeficiente de 1/3 (um terço), chegando-se a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

De outro lado, levando-se em conta a tentativa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela intervenção dos policiais - diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ADRIANO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA como incurso no artigo 155, § 1º; e § 4º, incisos I e II; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, "d", todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de

reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da extensa ficha criminal do acusado, o qual ostenta péssimos antecedentes e é duplamente reincidente específico. Pontue-se, pois oportuno, que ADRIANO, posto em liberdade após novo cumprimento de pena criminal, voltou a delinquir sem titubear, fato que desvela a imprescindibilidade do regime mais severo.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA